



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANILAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 14-08-2024 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-014092.989.24-3

Representante: Júlia de Souza Ferreira da Costa Soares

Representada: Prefeitura Municipal de Santos

Assunto: Exame prévio do edital do Pregão Eletrônico nº 14.005/2024, do tipo menor preço por item, destinado ao “registro de preços visando ao fornecimento de jogos do Projeto MAJOG – Matemática em jogo, a serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação – SEDUC”.

Responsável: Rogério Santos (Prefeito)

Subscritora do edital: Cristina Abreu da Rocha Barletta (Secretário de Educação)

Advogada cadastrada no e-TCESP: Júlia de Souza Ferreira da Costa Soares (OAB/SP nº 492.760)

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS. FORNECIMENTO DE JOGOS DO PROJETO MAJOG – MATEMÁTICA EM JOGO. INDICAÇÃO DE OBRA EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS QUE VIABILIZEM O DIRECIONAMENTO DO CERTAME A PRODUTO OU MARCA ESPECÍFICA. INDEVIDA EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. AFRONTA AO ARTIGO 69 DA LEI 14.133/21. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1 - RELATÓRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



1.1 Trata-se de **exame prévio do edital** do Pregão Eletrônico nº 14.005/2024, do tipo menor preço por item, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS**, para o “registro de preços visando ao fornecimento de jogos do Projeto MAJOG – Matemática em jogo, a serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação – SEDUC”.

1.2 Insurgiu-se a **Representante** contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

- a) ausência de justificativas para a escolha do Projeto MAJOG – Matemática em Jogo, em detrimento de outros produtos existentes no mercado;
- b) inadequado estabelecimento de itens (02, 04, 06, 08 e 10)¹ destinados exclusivamente às microempresas e empresas de pequeno porte, porquanto seus valores orçados excedem o limite previsto no artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006;
- c) indevida reserva à apresentação de impugnações e pedidos de esclarecimento² apenas por meio eletrônico, a ser efetivada em campo próprio no sistema (*bllcompras.com*);
- d) exigência de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda municipal³, não condizente com o objeto licitado;
- e) incidência do reajuste contratual somente após decorridos doze meses da vigência da ata de registro de preços⁴, em descompasso com o artigo 135, § 3º, da Lei nº 14.133/21;

¹ • Valor total estimado da Contratação: Item 01 – R\$ 1.057.207,80 Item 02 – R\$ 352.402,60 Item 03 – R\$ 1.018.763,88 Item 04 – R\$ 339.587,96 Item 05 – R\$ 1.254.232,89 Item 06 – R\$ 418.077,63 Item 07 – R\$ 1.210.983,48 Item 08 – R\$ 403.661,16 Item 09 – R\$ 1.146.910,28 Item 10 – R\$ 381.235,54 Item 11 – R\$ 46.697,20 Item 12 – R\$ 44.999,12 Item 13 – R\$ 49.244,32 Item 14 – R\$ 47.546,24 Item 15 – R\$ 44.999,12.

² 4.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados por forma eletrônica, através de campo próprio do sistema.

³ 1.1.8. Prova de regularidade fiscal apara com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, composta de Certidão Negativa de Tributos Mobiliários ou Positiva com efeito de negativa, expedida pela Secretaria de Finanças do Município, ou outro meio equivalente admitido em lei.

⁴ 5. DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Decorridos 12 (doze) meses da vigência da Ata de Registro de Preços e, havendo prorrogação da vigência, os preços registrados serão reajustados de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do período, observada a legislação federal em vigor.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



f) ausência de critérios de atualização monetária e incidência de juros decorrentes de atraso no pagamento, em afronta ao artigo 92, inciso V, da Lei nº 14.133/21.

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi concedida liminarmente por este E. Plenário.

Na oportunidade, destacou-se que “o *Projeto MAJOG – Matemática em jogo, ora licitado pela Administração, constitui programa já existente no mercado, desenvolvido pela empresa MVT Educação*⁵”, tendo o Plenário desta Corte decidido, em situação análoga, pela impossibilidade de indicação de fornecedor específico, sem que haja robusta motivação para tanto.

Afora isso, foram solicitadas justificativas acerca da exigência de certidão negativa de concordata, recuperação judicial ou extrajudicial⁶, por exceder o disposto no artigo 69, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

1.4 Regularmente notificada, a **Representada** apresentou justificativas da responsável pela Secretaria da Educação, no sentido de que teria sido “*realizado um Estudo Técnico Preliminar ETP - Projeto Majog Matemática em Jogo, conforme determina a legislação em vigor e que se encontra no Processo Administrativo nº 018232/2024-8*”. Afirmou que, em referido estudo, haveria descrição da necessidade de aquisição e o público-alvo (1º ao 5º ano - séries iniciais), elencando para cada série: eixo, jogos, conteúdo e materiais.

⁵ <https://mvteducacao.com.br/projetos-educacionais/majog/>

⁶ 1.1.14. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da empresa ou de execução patrimonial do domicílio da pessoa física ou da firma individual, cuja data de emissão não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura desta licitação.

1.1.14.1. Será admitida a apresentação de Certidão Positiva para a(s) licitante(s) em recuperação judicial ou extrajudicial, desde que acompanhada de seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico-financeiras estabelecidos neste edital.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



Esclareceu que os itens 02, 04, 06, 08 e 10 foram destinados às microempresas e empresas de pequeno porte, respeitando-se o limite de 25% do quantitativo da cota principal – ampla participação.

Aduziu que *“o encaminhamento da impugnação pela mesma plataforma em que é realizado o Pregão Eletrônico não restringe o direito de petição; ao contrário, justamente, visa facilitar o envio e conhecimento de todos os interessados no certame, a fim de atender a exigência do parágrafo único, art. 164 da Lei Federal n' 14.133/2021”*. Sublinhou, ainda, ter sido *“recomendação do próprio TCESP em outros Editais o recebimento de impugnação e esclarecimento de forma eletrônica, justamente para facilitar o envio”*.

Argumentou, ainda, que a exigência de regularidade fiscal *“faz parte da relação de documentos na minuta de edital padrão para Registro de Preços, aprovada pela PROJUR, através da Resolução PGM nº 03/2024, e está de acordo com o disposto no inciso III, art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021”*.

No mesmo sentido foram as justificativas em relação à ausência de cláusula de correção monetária e incidência de juros por atraso no pagamento, que teria seguido minuta de edital-padrão para Registro de Preços, aprovada pela Procuradoria Geral do Município - PROJUR.

1.5 O **Ministério Público de Contas** pronunciou-se pela parcial procedência das impugnações.

Afastou as críticas relacionadas à reserva de cotas às microempresas e empresas de pequeno porte e à regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal, ressaltando, nesta última questão que, por oportunidade do julgamento de habilitação dos licitantes, *“os responsáveis pela avaliação dos documentos deverão aferir apenas a regularidade fiscal perante os tributos que tenham incidência sobre o objeto licitado, em atenção ao artigo 68 da Lei nº 14.133/21”*.

No mais, avaliou inexistir *“no texto editalício ou nos anexos que o acompanham, nem nos esclarecimentos prestados pela Prefeitura, a demonstração da vantajosidade das obras da citada empresa em detrimento das*



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



demais soluções disponíveis no mercado, de modo a evidenciar que as obras da MVT Educação seriam as únicas capazes de atender adequadamente a Base Nacional Comum Curricular – BNCC”.

Entendeu ser pertinente que o edital amplie os mecanismos de impugnações e pedidos de esclarecimentos, bem assim que passe a prever *“como data-base para a correção monetária dos valores do ajuste a ‘data limite para apresentação da proposta ou do orçamento’, em atenção ao §7º do artigo 25 da Lei nº 14.133/21 e artigo 3º, §1º, da Lei nº 10.192/01”.*

Igualmente, destacou a necessidade de que sejam incluídas cláusulas fixando os critérios de compensação financeira no caso de atrasos nos pagamentos devidos pela Administração, conforme artigo 92, inciso V, da Lei 14.133/21.

Sublinhou que a *“exigência, como requisito de habilitação, de ‘Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial’ extrapola as previsões do artigo 69 da Lei nº 14.133/2112 e deverá ser excluída do edital, dada a falta de fundamento legal”.*

Além disso, pugnou por propor à Prefeitura que reavalie a escolha da sistemática do registro de preços para a aquisição dos produtos postos em disputa.

1.6. A seu turno **SDG** destacou inexistirem *“elementos essenciais a amparar a escolha do objeto licitado pela Administração, especialmente o cotejo entre o objeto pretendido e as demais opções existentes no mercado, demonstrando-se inequivocamente que se trata da solução mais vantajosa, conforme determinado pelo artigo 18, § 1º, V, da Lei nº 14.133/21”.*

No mais, considerou procedentes as críticas relacionadas ao prazo para reajuste de preços, exigência de certidão negativa de concordata, recuperação judicial ou extrajudicial e a necessidade de inclusão das cláusulas prevendo os critérios de correção monetária e de incidência de juros nos casos de atraso de pagamento por culpa do Contratante.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



Especialmente em relação ao reajuste, ponderou que a estipulação do início da vigência da Ata como data-base para o reajustamento seria irregular, pois a Nova Lei de Licitações determinaria que fosse ela vinculada ao orçamento estimado, consoante o disposto no artigo 25, § 7º, da Lei nº 14.133/21.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Santos pretende o *“registro de preços visando ao fornecimento de jogos do Projeto MAJOG – Matemática em jogo, a serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação”*.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação pertinente e à jurisprudência desta Corte.

2.2 De início, considero procedente a crítica direcionada à ausência de justificativas para a escolha do Projeto MAJOG – Matemática em Jogo, em detrimento de outros produtos existentes no mercado.

Conforme destaquei por oportunidade da suspensão do certame, mencionado projeto *“constitui programa já existente no mercado, desenvolvido pela empresa MVT Educação⁷”*, tendo este Plenário já decidido, em situação análoga, pela impossibilidade de indicação de fornecedor específico, sem que haja robustas justificativas para tanto.

Necessário frisar que não se discute a relevância da opção pedagógica ora pretendida pela Administração, assim como não se questiona a qualidade do material eleito. No entanto, a despeito da discricionariedade de que se reveste os atos do Administrador, certo é que devem ser eles motivados.

⁷ <https://mvteducacao.com.br/projetos-educacionais/majog/>



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



E essa motivação, no caso, revela-se inconsistente. O Estudo Técnico Preliminar – ETP, citado pela Representada em suas justificativas (e constante do evento nº 27.6), limita-se a descrever, de maneira sucinta, o Projeto MAJOG – Matemática em Jogo⁸, apresentando o material de apoio a ser disponibilizado, de acordo com a série cursada.

Aliás, também se mostram superficiais os quesitos sobre os resultados pretendidos⁹ e a viabilidade da contratação¹⁰.

Como bem observou o MPC, não foram em nenhum momento apresentados os diferenciais desse Projeto em relação aos demais existentes no mercado, tampouco a vantagem econômica de sua contratação.

Impende registrar que este Plenário em recente oportunidade (sessão de 17-04-24), acolhendo voto de minha relatoria, nos autos do processo TC-8678.989.24-5, assim decidiu:

“De plano, revela-se indevida a indicação de obra específica, em detrimento de outras existentes no mercado, sem que tenham sido apresentadas robustas justificativas para tanto.

Como destacado pelo MPC, o ‘Termo de Referência, além de tecer comentários a respeito da importância do ensino da educação financeira nas escolas, apresentando as normas legais vinculadas ao tema da educação, justifica a necessidade da aquisição dos livros ‘Programa de Educação Financeira e empreendedorismo para a vida’, da editora Ciranda Cultural, na ‘análise pela equipe pedagógica da Secretaria de Educação de Barueri’, sem adentrar nos fundamentos por ela adotados’.

⁸ 7- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Jogos podem trazer benefícios não só na aprendizagem de conceitos matemáticos, mas na capacidade de relacionar em grupo, diminuindo a timidez, e aumentando a socialização dos alunos. Como geralmente são praticados em duplas ou mais componentes, essa interação resgata o hábito do diálogo entre as pessoas, que está se perdendo em meio a tantas tecnologias. Motiva ainda o respeito às regras e combinados; Projeto MAJOG - Matemática em foco tem o objetivo de garantir o avanço da aprendizagem em Matemática. Ele tem como ponto de partida as competências e habilidades a serem adquiridas pelos estudantes, propostas pela BNCC. É também, uma excelente ferramenta de: mobilização cognitiva, resolução de problemas e socialização de hipóteses, que trata o aluno como protagonista no processo de aprendizagem. Ele é implementado com o treinamento e acompanhamento in loco de uma equipe pedagógica especializada, o que sugere robustez ao projeto.

⁹ 9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se contratar os itens deste processo pelo menor preço, até o limite do preço unitário máximo estimado, com a qualidade, especificações e exigências descritas visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação.

¹⁰ 13 — VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

O material apresenta às crianças e professores um conjunto de jogos, tanto novos quanto “tradicionais, que permitem o aprendizado de conteúdos essenciais à vida escolar das crianças é que atendem ao Currículo Santista. Para isso, cada jogo é pensado como disparador e alimentador -de uma sequência de atividades que permita aos alunos se apropriarem de conhecimentos matemáticos, usando-os de forma consciente e com segurança.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



Por sua vez, a defesa limita-se a defender a discricionariedade do Administrador para avaliar o que atenda ao interesse público, apontando apenas que a escolha da obra foi definida “adequadamente, com a observância dos princípios pedagógicos determinados pelo corpo docente” e pelas diretrizes do Ministério da Educação.

Ausente, ainda, estudo comparativo entre as diversas soluções ofertadas pelo mercado, que evidenciem ser as obras da citada editora as únicas capazes de atender adequadamente à Base Nacional Comum Curricular – BNCC.

Recordo que, por iguais motivos, este Plenário já determinou a reforma de outro edital lançado pela Prefeitura Municipal de Barueri, nos autos do processo TC-008020.989.23-2¹¹, sob relatoria do e. Conselheiro RENATO MARTINS COSTA, cujo objeto, análogo ao presente caso, era a aquisição de ‘Kits de livros do Programa de Educação Financeira’, nos seguintes termos:

‘Ressalto, a bem da verdade, que a promoção de ações públicas voltadas ao desenvolvimento da Educação Financeira nas Escolas merece ser positivamente reconhecida e, num cenário mais amplo, aferida conforme as diretrizes estabelecidas a partir da nova Estratégia Nacional de Educação Financeira (Decreto Federal nº 10.393/2020), inclusive porque ao tema se atribui a condição de disciplina obrigatória que, inserida na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), deve integrar a grade curricular dos Ensinos Fundamental e Médio das Escolas Públicas em todo o país.

Essencial, entretanto, que a Prefeitura de Barueri informasse a este Relator sobre os pressupostos técnico-jurídicos que teriam fundamentado o processo licitatório questionado, notadamente no que se refere à metodologia de ensino eleita, uma vez que tal opção configuraria expressa condição de participação na disputa, representando, assim, elemento em alguma medida determinante ao dimensionamento do universo de proponentes.

Afinal, ainda que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional confira aos estabelecimentos de ensino a incumbência de elaborar e executar suas propostas pedagógicas com autonomia, não seria de plano improvável a existência de outros editores e métodos de ensino bastantes para igualmente formar e informar estudantes do Ensino Fundamental na aludida disciplina obrigatória.

E para uma compreensão um pouco mais elástica dos desmembramentos que tal opção administrativa pode gerar, mesmo que nos limites desta análise apriorística por excelência, quero crer que não caberia à Prefeitura, no propósito de implementar ações destinadas ao Programa de Educação Financeira em suas Escolas, esquivar-se de tais questionamentos.

Digo isso, fundamentalmente, porque a referida Estratégia de Educação Financeira (ENEF) partiu de um

¹¹ Sessão Plenária de 24-05-23.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



modelo conceitual suficiente para estabelecer princípios e correspondentes orientações destinadas a levar a Educação Financeira às Escolas, incluindo a produção do correspondente material didático necessário à capacitação de professores e ao aprendizado dos alunos, material esse de livre e gratuito acesso por meio da plataforma digital do ENEF (vidaedinheiro.gov.br).

Tratada a disciplina como matéria transversa da referida Estratégia de Governo, portanto, à Prefeitura de Barueri estaria disponível, como de fato me parece estar, coleção completa de livros suficientes para se ministrar os estudos e conceitos de Educação Financeira ao longo dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Não se justifica, ao menos no contexto desta análise de Exame Prévio de Edital, que o Instrumento Convocatório e seu Termo de Referência de plano remetam as licitantes ao material da Editora DSOP, por mais que tal metodologia possa ser idônea e de conteúdo técnico aprovado, discriminação que adicionalmente não se sustenta diante do fato de que o modelo de Educação Financeira nas Escolas estabelecido a partir da Estratégia Nacional que o formata igualmente franqueia às Escolas, professores e alunos material digital adequado aos exatos fins.

Não bastasse, esse mesmo conjunto de características igualmente revela que o objeto pretendido, ainda que do ponto de vista do desenvolvimento de ações pedagógicas possa apresentar algum traço de instrumentalidade, a condição de disciplina curricular obrigatória suprime qualquer atributo paradidático que pudesse, por exemplo, justificar a incidência de preceitos de discricionariedade como medida de integração de eventual opção antecipada por certa metodologia educacional.

Ausentes tais fundamentos, de rigor compreender que a opção pela aquisição dos kits de livros no mercado e, portanto, mediante a geração de despesa pública, vis-à-vis da possibilidade do emprego concorrente de material didático de acesso gratuito, desqualifica o modelo que o Pregão em questão propõe em sua origem, mais ainda por conceder ao fornecedor específico tratamento privilegiado que não encontra na norma constitucional fundamento de validade.

Esse, para mim, o ponto mais sensível da presente análise e que, não tendo sido rigorosamente enfrentado pela Representada, condena neste rito toda a finalidade do Pregão instaurado". (Grifei)

Aliás, necessário destacar que nessa mesma linha foi a recente decisão proferida por este Plenário, em sessão de 10-04-2024, nos autos do processo TC-007019.989.24-3, sob minha relatoria.

Nesta esteira, necessário que a Administração reavalie as especificações do objeto, fundamentando sua escolha, se for o caso, em estudos robustos que demonstrem, de maneira incontestada, a singularidade do produto almejado frente às demais soluções existentes no mercado, bem como a multiplicidade de distribuidores aptos a fornecer o produto".



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



Desta forma, e na linha do precedente citado, indispensável a realização de estudos técnicos que demonstrem a singularidade e vantajosidade do projeto escolhido em relação aos demais existentes no mercado, assim como os distribuidores aptos a fornecê-lo.

2.3 Ademais, encontra-se superado o enunciado da Súmula nº 50 pelo disposto no artigo 69, inciso II, da Lei nº 14.133/21, o que impõe seja excluída a exigência de certidão negativa de concordata, recuperação judicial ou extrajudicial.

2.4 Oportuno, ainda, que sejam incluídas cláusulas fixando os critérios de compensação financeira no caso de atraso nos pagamentos devidos pela Administração, conforme estabelece o artigo 92, inciso V, da Lei 14.133/21.

2.5 No tocante ao reajuste contratual, o exame da cláusula impugnada (5.1) exige redobrada cautela.

De um lado, conforme argumenta a Representante, os artigos 25, § 7º, e 92, § 3º, da Lei nº 14.133/21, estabelecem que a data-base para essa finalidade é a do orçamento estimado.

Todavia, a aplicabilidade dessa norma ao caso é controvertida, sendo necessário reconhecer que a mesma Lei nº 14.133/21 conferiu nova, específica e mais detalhada sistemática ao registro de preços, incluindo a possibilidade, agora expressamente consagrada em seu artigo 84, de prorrogação da respectiva ata, “desde que comprovado o preço vantajoso”.

O fato é que a Nova Lei de Licitações busca assegurar a atualidade dos valores, mediante prova de manutenção da vantajosidade na hipótese de prorrogação da ata, mas também ao estabelecer que o edital de licitação disponha sobre a alteração e a atualização periódica dos preços registrados, nos termos do artigo 82, inciso VI, e § 5º, inciso IV.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



A propósito, não se pode olvidar que os artigos 82 a 86 da Lei nº 14.133/21 foram regulamentados pelo Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, cujo artigo 25 tem a seguinte redação:

Art. 25. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

I - em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

II - em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; ou

III - na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos do disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

Diante do alcance do inciso III supratranscrito, a cláusula impugnada não parece ostentar manifesta ilegalidade, passível de reconhecimento em sede de cognição sumária, típica do exame prévio de edital.

Impende salientar, ademais, que *“a existência de preços registrados (...) não obrigará a Administração a contratar”* (artigo 83), razão pela qual deve ela sempre atentar para a manutenção da vantajosidade dos valores constantes em ata.

Por outro lado, o edital deve se adequar a outros aspectos do artigo 82 e seguintes da Lei 14.133/21, consignando as regras ali previstas, dentre as quais destaco: as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas consequências; e o estabelecimento de rotina de controle.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



2.6 Por sua vez, insubsistente a crítica relacionada à reserva de cota às microempresas e empresas de pequeno porte, pois em conformidade com o disposto no inciso III do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/06, que impõe, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, seja estabelecida cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação daquelas entidades.

Há de se destacar que, a despeito da nomenclatura utilizada pela BLLC, a reserva de cota mencionada no inciso II, e aplicada no presente certame, não se confunde com a exigência de destinação exclusiva do torneio às MEs e EPPs, nas contratações cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), prevista no inciso I.

De todo modo, nos termos disciplinados pelo artigo 49, avaliou a Administração que a divisão em itens destinados àquelas empresas não traria prejuízo *“ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado”*.

2.7 Outrossim, o posicionamento desta Corte, que considero prevalecer com as disposições da Nova Lei de Licitações, tem sido no sentido de não haver ilegalidade na requisição genérica de prova de regularidade fiscal, nos moldes do que, inclusive, preceitua o artigo 68, inciso III, da Lei nº 14.133/21, cabendo à licitante demonstrar sua regularidade perante os tributos que incidam sobre a sua atividade.

Aliás, como bem destacado pelo MPC, *“os tributos mobiliários não se limitam ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, como quer fazer crer o representante, podendo referir-se também a taxas pelo exercício do poder de polícia (taxas de fiscalização, por exemplo)”*.

De todo modo, com o Órgão Ministerial, considero pertinente alertar a Administração para que, na análise dos documentos de habilitação, circunscreva-se a aferir a regularidade fiscal dos tributos compatíveis com o objeto licitado.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



2.8 Afasto, ainda, a queixa alusiva à apresentação de impugnações e pedidos de esclarecimentos apenas por meio eletrônico, pelas mesmas razões por mim externadas nos autos do TC-14049.989.20-5 e acolhidas por este Plenário, em sessão de 08-07-20:

“Especificamente acerca da impossibilidade de recebimento de impugnações e de pedidos de esclarecimentos por outros meios que não através da utilização da Bolsa de Licitações do Brasil - BLL (subitens 4.1 e 4.1.1 do edital), permito-me discorda da instrução da matéria.

A hipótese que ora se apresenta difere daquela, reiteradamente reprovada por esta Corte, em que o ente licitante limita a apresentação de tais documentos ao protocolo presencial, inviabilizando o exercício desse direito para licitantes que não possam comparecer diretamente à sede do órgão contratante.

Aqui se examina um pregão eletrônico, cujos atos devem ocorrer naquele ambiente, o que garante, sobretudo, a transparência e isonomia entre as interessadas. Estranho seria, no caso, permitir impugnações e esclarecimentos via protocolo presencial.

Nos editais desta Corte, que utilizam a BEC – Bolsa Eletrônica de Compras, a redação conferida à disposição da espécie não se distancia da ora em análise:

“ESCLARECIMENTOS OU IMPUGNAÇÕES: até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá, por meio do sistema eletrônico, solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico. A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações, será formulada em campo próprio do sistema, encontrado na opção EDITAL e serão respondidos pelo subscritor do Edital, no prazo de até 1 (um) dia útil, anterior à data fixada para abertura da sessão pública”. (Grifei)

Destarte, tratando-se de edital eletrônico, considero insubsistente a crítica formulada”.

2.9 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

a) realizar estudos que demonstrem a singularidade e vantajosidade do projeto escolhido em relação aos demais existentes no mercado, assim como a multiplicidade de distribuidores aptos a fornecê-lo;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



- b) excluir a exigência de certidão negativa de concordata, recuperação judicial ou extrajudicial;
- c) incluir cláusulas fixando os critérios de compensação financeira no caso de atraso nos pagamentos devidos pela Administração;
- d) consignar as regras previstas no artigo 82 e seguintes da Lei 14.133/21, acerca do registro de preços, caso mantida referida sistemática;
- e) circunscrever-se, na análise dos documentos de habilitação, a aferir a regularidade fiscal dos tributos compatíveis com o objeto licitado.

Recomendo, outrossim, nos termos propostos pelo MPC, que a Administração reavalie a escolha da sistemática do registro de preços para a aquisição dos produtos almejados.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2024.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO